

1515301-39.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: MARCIO LUCIO FALAVIGNA SAUANDAG

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 22ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 22/08/2022

... Tudo porque a prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes independe da efetiva venda da droga, estando bem delineada nos autos a configuração do delito de tráfico na modalidade de "transportar" o entorpecente.

Assim, as provas confirmaram os elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, o que confere um quadro de certeza quanto aos termos da imputação dada ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

22ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, Nº 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1515301-39.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1515301-39.2022.8.26.0228

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RAFAEL DA SILVA SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARCIO LUCIO FALAVIGNA SAUANDAG

Vistos.

RAFAEL DA SILVA SANTOS, foi denunciado e se vê processado pela prática do crime descrito no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 c/c art. 61, inciso II, alínea "j)", do Código Penal, porque, no dia 04 de julho de 2022, por volta das 23h05min, durante a vigência do Decreto Estadual nº 64.879, de 20 de março de 2020 e Decreto Federal nº 06/2020 (decretos de calamidade pública), na Rua Doutor Laerte Setubal, nº 10, Vila Andrade, nesta cidade e Comarca, transportava, para fins de entrega a consumo de terceiros, 02 (dois) tijolos de cocaína, pesando 2.000g (duas mil gramas) e 55 (cinquenta e cinco) tijolos de maconha, pesando 48.904,6g (quarenta e oito quilogramas, novecentos e quatro gramas e seis decigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 16 e laudo de exame químico-toxicológico de fls.19/22.

Recebida a Denúncia, o acusado foi citado, apresentando Resposta à Acusação, seguindo-se a decisão saneadora.

Em audiência foi colhida a prova oral e interrogado o acionado.

Ponderações finais das partes em debates.

Auto de Exibição e Apreensão do Entorpecente, a fls. 16.

Laudo de Constatação a fls. 19/22.

Laudo de Exame Químico-Toxicológico, a fls. 92/94.

É o relato do quanto necessário.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A condenação é reclamada.

A materialidade do crime encontra esteio no Auto de Exibição e Apreensão de fls. 16, Laudo de Constatação de fls. 19/22 e Laudo Pericial de fls. 92/94, onde se infere que os materiais apreendidos com o acionado, se tratavam, efetivamente, de substâncias entorpecentes, no caso, cocaína e maconha.

A autoria do crime de tráfico imputado ao acionado ecoa da prova produzida, evidenciada sua participação ativa em atos de traficância.

Interrogado na fase policial, o acionado silenciou, atitude que não se espera de quem se diz inocente (fls. 08).

Em audiência, negou a acusação.

Contudo, apresentou discurso fantasioso e inventivo, de todo embusteiro e inverossímil, isolado no contexto da prova, revelador, unicamente, do espírito aguerrido e aventureiro do criminoso, de simplesmente pretender negar o óbvio, com nítido desprezo ao bom senso, algo a que não me atrevo, tampouco posso admitir. Triste investida!

Doutro lado, temos o restante da prova acusatória, de todo séria, encimada nos relatos dos policiais militares responsáveis pela abordagem e prisão em flagrante do réu.

Em Juízo, sob o crivo do contraditório, as testemunhas Thiago Camargo Gomes e João Carlos Alba Junior, em depoimentos absolutamente harmônicos, firmes e sérios, declararam que estava em patrulhamento, oportunidade em que visualizaram o acionado conduzindo o veículo no contrafluxo da via, tendo demonstrado certo nervosismo ao perceber a presença da guarnição, o que foi determinante para que realizassem a abordagem, mesmo porque, numa primeira tentativa de contato, deu de ombros, esboçando tentativa de fuga, reforçando a desconfiança de que algo errado ocorria, de forma que agiram com vigor, conseguindo realizar a abordagem em poucos metros, visto que o trânsito, na trajetória seguida pelo acionado, parou por conta do fluxo intenso. Feita a revista pessoal, nada de ilícito encontraram. Entretanto, feita a revista veicular, encontraram inúmeros tijolos de substância entorpecente. Indagado, não soube explicar onde havia retirado a droga, pois não conhecia ao certo a região. Entretanto, informou que levaria a droga para a cidade de Cubatão, de onde natural.

Neste quadro, dúvida não me paira de que o acionado transportava, enorme quantidade de drogas, consistentes em 02 (dois) tijolos de cocaína, pesando 2.000g (duas mil gramas) e 55 (cinquenta e cinco) tijolos de maconha, pesando 48.904,6g (quarenta e oito quilogramas, novecentos e quatro gramas e seis decigramas), marcadamente destinadas à entrega para o consumo de terceiros, mormente porque o acionado não demonstrou condições econômicas para ter tamanha quantidade de drogas unicamente para seu deleite pessoal, alegação que seria verdadeiramente teratológica, sequer comprovando possuir emprego lícito.

Consigno que nada há nos autos a indicar que os policiais, por motivo egoístico ou leviano, tivessem urdido macabra trama, como única pretensão na vida acusar o acionado, sabendo se tratar de pessoa inocente.

No caso em espécie, nenhuma razão séria foi levantada para que se colocasse em dúvida a idoneidade das testemunhas policiais ou gerasse suspeita de especial motivo para prejudicar o acusado.

A enorme quantidade de drogas apreendidas, num total de 50.904,6 (cinquenta mil quilogramas, novecentos e quatro gramas e seis decigramas), entorpecentes de natureza variada e altamente lesivas, a forma de armazenamento, a apreensão dos entorpecentes no porta malas do veículo do acionado, as circunstâncias do flagrante, precedido de comunicação do crime à Polícia Civil, os depoimentos firmes dos policiais que detiveram o acusado, enfim, todo o arcabouço probatório aponta para a conclusão inarredável de que o acusado efetivamente praticou a conduta criminosa que lhe é imputada pelo Órgão Ministerial.

De tal forma, da prova se extrai que efetivamente o réu praticou a conduta descrita na Denúncia, sendo inviável a pretensão absolutória ou desclassificatória.

Com efeito, irrelevante se mostra a não identificação precisa do cliente. Tudo porque a prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes independe da efetiva venda da droga, estando bem delineada nos autos a configuração do delito de tráfico na modalidade de “transportar” o entorpecente.

Assim, as provas confirmaram os elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, o que confere um quadro de certeza quanto aos termos da imputação dada pelo Ministério Público.

E pese embora o esforço da Defesa, não há qualquer mácula na prova, sendo seu entendimento respeitável, mas peculiar.

Com efeito, o disposto no art. 5º, inciso X, da Carta da República, não se mostra, tampouco pode se mostrar, como um salvo conduto para práticas criminosas.

No caso, com os olhos na realidade, e não com a cabeça nas nuvens, temos que o acionado transportava mais de cinquenta quilos de drogas, em carro de locadora, cuja posse não pretendeu esclarecer, oportunidade em que despertou a suspeita dos policiais, com tirocínio aguçado, visto ter se mostrado incomodado com a presença da guarnição, os quais deliberaram pela abordagem, de todo exitosa, pese embora a tentativa de fuga, frustrada pelo empenho dos agentes da Lei.

Qual nulidade na abordagem? Óbvio que nenhuma, realizada nos limites da Lei (art. 244, do CPP), e da proteção da sociedade.

Ora, como bem claro na prova, houve fundada suspeita aos policiais para a realização da abordagem e vistoria. Com a aproximação, ainda, o acionado pretendeu fuga, acelerando o veículo, o que demandou pronta e firme intervenção da polícia para que estancasse a marcha.

Se tal postura do acionado não é fundada suspeita, respeitado entendimento contrário, não sei o que poderia ser.

Ou seja, absolutamente legal a conduta dos policiais, donde decorre farto material probatório lícito para indicar a responsabilidade do acionado pela prática do crime de tráfico de drogas em larga escala.

Importante destacar, ainda, que a ação policial efetuada nesse caso não pode ser considerada ilegal, simplesmente porque o acionado estava em situação de flagrante de delito permanente. E, como se sabe, a situação de flagrante permanente, tal como se dá nos casos de delito de tráfico de drogas, dispensa a apresentação de mandado judicial de busca, na esteira do que preceitua o artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal e artigos 242 e 244, ambos do Código Penal (Habeas Corpus Criminal nº 2267082-98.2021.8.26.0000, 7ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, j. em 14 de janeiro de 2022, rel. Desembargador FREITAS FILHO).

Neste sentido, ainda: Ao contrário do que sustenta a combativa defesa, não se verifica qualquer em ilicitude de provas colhidas por suposta ausência de fundadas razões para a revista pessoal. Como restou demonstrado, os policiais agiram dentro dos parâmetros legais. O réu demonstrou nervosismo ao perceber a presença policial, pelo que legítima a abordagem, que culminou com a apreensão de drogas descritas na denúncia. Legitimou-se a prisão em flagrante delito porque o réu estava na posse de dinheiro, indicou o local em que se encontrava as drogas, justamente sob uma telha, defronte à sua pessoa. Assim, evidenciado que a busca pessoal foi em decorrência de cumprimento de obrigação constitucional e legal dos policiais, fundada na suspeita apresentada pelo réu. Veja-se que o art. 240, § 2º, do Código de Processo Penal é claro em sua redação, ao exigir que a busca pessoal seja realizada quando houver fundada suspeita da posse dos objetos ali arrolados: Art. 240. A busca será domiciliar ou pessoal. § 2o. Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras b a f e letra h do parágrafo anterior. Evidente que a conduta do acusado ao se demonstrar desconfortável com a presença da polícia no local se releva como hipótese de fundada suspeita. Nesse sentido, a doutrina ensina que a fundada suspeita: “é requisito essencial e indispensável para a realização da busca pessoal, consistente na revista do indivíduo. Suspeita é uma desconfiança ou suposição, algo intuitivo e frágil, por natureza, razão pela qual a norma exige fundada suspeita, que é mais concreto e seguro. Assim, quando um policial desconfiar de alguém, não poderá valer-se, unicamente, de sua experiência ou

pressentimento, necessitando, ainda, de algo mais palpável, como a denúncia feita por terceiro de que a pessoa porta o instrumento usado para o cometimento do delito, bem como pode ele mesmo visualizar uma saliência sob a blusa do sujeito, dando nítida impressão de se tratar de um revólver. Enfim, torna-se impossível e impróprio enumerar todas as possibilidades autorizadoras de uma busca, mas continua sendo curial destacar que a autoridade encarregada da investigação ou seus agentes podem e devem revistar pessoas em busca de armas, instrumentos do crime, objetos necessários à prova do fato delituoso, elementos de convicção, entre outros, agindo escrupulosa e fundamentadamente." (in NUCCI, Guilherme de Souza, Código de Processo Penal Comentado, 19.ed., Rio de Janeiro: Forense, 2020, p. 556 grifos nossos). Deste modo, nenhuma nulidade há de ser declarada, ficando afastada a preliminar aventada (Apelação Criminal nº 1506370-81.2021.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, 7ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, j. em 29 de setembro de 2021, rel. Desembargador FERNANDO SIMÃO).

Bem firmadas as responsabilidades do réu pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, passo a mensurar as reprimendas adequadas.

Em primeira fase, as circunstâncias judiciais se mostram desfavoráveis ao acionado. Consoante apurado, o acionado foi preso com elevadíssima quantidade de drogas, apreendidas no porta malas do veículo que conduzia, num total de 50.904,06 (cinquenta mil, novecentos e quatro gramas e seis decigramas) de entorpecentes de natureza variada e, dentre elas, de drogas extremamente lesivas, das quais destaco, a cocaína.

Tal situação exacerba a reprovabilidade insita ao tipo penal abstrato, merecendo maior rigor por parte do Poder Judiciário, na aplicação da lei.

Mesmo porque, verifico que o acionado ostenta maus antecedentes criminais, conforme certidão de fls. 24/27 (processo nº 0040990.55.2007 - 1ª Vara Criminal da Comarca de Santos), não se mostrando jejuo ou debutante.

Importante destacar que o Pretório Excelso no julgamento do Recurso Extraordinário nº 593.818, com repercussão geral reconhecida, fixou, por maioria de votos, a tese de que "Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal". Destarte, com fundamento no art. 42 da Lei nº 11.343/06 e art. 59, do Código Penal, fixo as penas-base do acusado em dez anos de reclusão e pagamento de pena pecuniária em valor correspondente a hum mil dias multa.

Em segunda fase, ausentes circunstâncias atenuantes, observo que o acionado é reincidente específico, conforme se extrai da certidão de fls. 24/27, tendo sido condenado em definitivo, pela prática do crime de tráfico de drogas (processo nº 0023619.28.2015 - 1ª Vara Criminal de Cubatão).

Assim, considerando-se a circunstância desfavorável acima colocada, consistente em reincidência específica/qualificada, majoro suas reprimendas em 1/5, encerrando o cumprimento de pena privativa de liberdade de doze anos de reclusão, bem como o pagamento de pena pecuniária em valor equivalente a hum mil e duzentos dias multa. Revendo posicionamento anterior, me convenço que na espécie não seja o caso de reconhecer a agravante descrita na denúncia (crime praticado durante período de calamidade pública), ausente, na prova, qualquer indicativo concreto de que o acionado se prevaleceu da pandemia para a prática do crime em questão, o que seria imprescindível a render espaço para reconhecimento da agravante.

Confira-se: Agravante prevista pelo art. 61, II, alínea j, do CP não prospera. A situação de calamidade em nada facilitou a ação criminosa, não havendo que se falar em enfraquecimento na proteção do bem jurídico diante do estado emergencial e de aproveitamento do acusado daquela situação. (Apelação Criminal nº 1511782-27.2020.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, 16ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, j. em 18 de março de 2022, rel. Desembargador Marcos Alexandre Coelho Zilli)

Ou seja, ausente prova do nexo de causalidade entre a pandemia e a conduta imputada ao acionado, incomprovado, então, que o acionado tenha se valido de alguma fragilidade ensejada pela pandemia para praticar o crime, seu reconhecimento se mostra impossível.

Sobre o tema, ainda: Habeas Corpus nº 625645-SP, rel. Ministros Félix Fischer; AgRg

no Habeas Corpus nº 717.298-SP, rel. Ministro Ribeiro Dantas; AgRg no HC 655.339/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca; AgRg no HC 669.508/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior.

Em terceira etapa da dosimetria, não há causas de aumento ou diminuição a ser consideradas, não sendo aplicável o redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, em se tratando de acusado reincidente específico.

Penas finais: cumprimento de pena privativa de liberdade de 12 (doze) anos de reclusão e pagamento de multa no valor equivalente a 1.200 (hum mil e duzentos) dias multa, fixados estes em seu valor unitário mínimo.

O sentenciado cumprirá a pena corporal aplicada pela prática do delito descrito no artigo 33, caput, da Lei Federal nº 11.343/06, no regime inicial fechado, considerando o quantum da pena corporal aplicada, superior a oito anos, aliado ao fato de que se trata de sentenciado específico, e ainda, tendo contra si circunstâncias judiciais absolutamente desfavoráveis, sendo descabido qualquer outro regime mais brando.

Ademais, de boa lembrança o comando que emerge do art. 2º, § 1º, da Lei Federal nº 8.072/90.

Por fim, vale frisar que o acusado foi preso em flagrante delito, na posse de enorme quantidade de drogas, o que justificou a exasperação de suas penas em primeira etapa. Deste modo, a gravidade concreta de sua conduta é nítida e merece repressão severa por parte do Poder Judiciário.

No que tange a eventual substituição da pena corporal pela restritiva de direitos, observo que o quantum da pena aplicada impede a concessão da benesse disposta no art. 44, do CP, eis que fixada muito acima do limite legal de quatro anos, conforme prevê o inciso I do citado artigo. Além disso, a substituição da pena privativa de liberdade encontra óbice na condição de reincidente específico que ostenta réu, nos exatos termos do artigo 44, inciso II, do CP. Não bastasse, a medida sequer seria recomendável (art. 44, inciso III, do CP). Assim, inviável aplicação de pena diversa da corporal.

Por fim, ao cabo, e de saída, entendo inaplicável o disposto no art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, à mingua de informações hábeis a respaldar a real situação processual do acionado, como um todo, de forma a permitir identificar a presença do requisito subjetivo, que indispensável à estipulação de regime diverso do imposto, já que se trata de uma forma, ou de outra, de verdadeira progressão, afeta ao Juízo da execução (art. 66, inciso III, da LEP).

Neste sentido: Apelação nº 0090669-32.2012, rel. Desembargador Roberto Solimene; Apelação nº 0008232-62.2010, rel. Desembargador Fernando Torres Garcia.

Ademais, tendo em conta a pena aplicada, e o tempo de custódia que descontou até então, não faz jus a qualquer benefício.

Acredito que mais, seja desnecessário aduzir, posto que nada mais pertine à análise, como forma de dirimir a controvérsia instalada.

Diante do exposto, e de tudo mais que dos autos consta, julgo PROCEDENTE o pedido e assim o faço para CONDENAR o réu RAFAEL DA SILVA SANTOS ao cumprimento de pena privativa de liberdade de 12 (doze) anos de reclusão, no regime inicial fechado, bem como ao pagamento de pena pecuniária em valor equivalente a 1.200 (hum mil e duzentos) dias-multa, fixados estes em seu valor unitário mínimo, na forma do art. 43 da Lei nº 11.343/06, por infringência ao disposto nos art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Sensíveis os requisitos que fundamentaram a conversão da prisão em flagrante em preventiva do réu, e ainda mais agora, tendo sido condenado a duras penas, de modo que, acaso posto em liberdade, invariavelmente não se colocará de modo voluntário ao cumprimento de suas reprimendas, mantenho a prisão preventiva do sentenciado. Assim se garante a ordem pública, bem como a aplicação da lei penal.

Transitada esta em julgado, que seja o nome do réu lançado no rol dos culpados.

Deixo de decretar a perda do veículo apreendido, utilizado no transporte de droga, na medida em que, aparentemente, se trata de carro pertencente a terceiro, no caso, Locadora de Veículos, terceiro cuja boa-fé se presume.

Contudo, DECLARO A PERDA do valor apreendido a fls. 16 (R\$ 209,00), em favor do FUNAD, posto que evidente produto da atividade espúria realizada pelo acionado. Com

o trânsito em julgado, providencie-se o necessário para transferência do valor, cobrando-se a vinda aos autos do respectivo depósito judicial. Arcará o condenado, com o pagamento das custas do processo, nos termos do art. 4º, § 9º, da Lei Estadual nº 11.608/03. Sentença dada e publicada em audiência, saindo os presentes cientes e intimados. P.R.I.C. São Paulo, 22 de agosto de 2022.

Assinatura digital, nos termos do art. 1º, § 2º, inciso III, alínea "a", da Lei Federal nº 11.419/06